EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI, PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA
ao **Min. Celso de Mello**, relator da ADI 5138, extinta sem resolução de mérito (art. 253, II, CPC).

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO - ANAPE, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n° 89.137.863/0001-19, com sede no SCS, Qd. 1, Bloco E, Edifício Ceará, salas 1001/1014, Brasília/DF, na condição de entidade de classe de âmbito nacional, nos termos dos artigos 102, I, "a" e 103, IX, da Constituição Federal e de acordo com o rito prescrito na Lei n° 9.869/99, vem por seus advogados, endereço para intimações no SHIS, QI 26, Conj.2,Casa 2, CEP 70.670-020, Brasília/DF, propor

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

contra a **Lei Complementar do Estado do Espírito Santo n. 739**, de 23 de dezembro de 2013, publicada no Diário Oficial de 24 de dezembro de 2013,

em razão de sua **incompatibilidade com o art. 132, *caput***, da Constituição, pelas razões que passa a expor.

I. Da legitimidade da requerente e da pertinência temática

A requerente ostenta condição de entidade de classe de âmbito nacional, que tem por finalidade precípua a defesa, em nível nacional, dos interesses dos Procuradores de Estado e do Distrito Federal relacionados com o seu exercício funcional, bem como agir no sentido de consolidar a advocacia de Estado como instituição essencial à Justiça.

Consta expressamente do art. 3°, inc. IX, do seu estatuto, como um dos seus objetivos "promover ações diretas de inconstitucionalidade contra qualquer lei ou ato normativo, mandados de segurança coletivo, mandado de injunção e demais ações cuja legitimação lhe seja outorgada por lei, com vistas à salvaguarda das prerrogativas dos Procuradores do Estado".

Em observância a tal disposição estatutária, a requerente vem a este Pretório Excelso para assegurar a atuação e defender a missão institucional dos seus membros do Estado do Espírito Santo, objetivando dessa forma a segurança jurídica, o respeito e a valorização da carreira da advocacia de Estado. Isso porque a criação, por lei complementar estadual, de categoria de **servidores técnicos com perfil de advogados**, funcionando como uma "**procuradoria paralela**" ou "**procuradores paralelos**" na Faculdade de Música do Espírito Santo, em clara afronta ao preceito do art. 132, da Constituição.

A legitimidade ativa da **ANAPE** para a provocação do controle abstrato de constitucionalidade em face de preceitos atinentes à mesma matéria aqui debatida já foi reconhecida por esta Excelsa Corte, sendo bastante mencionar o julgamento de mérito das ADIs n°s **1557**, relatora Ministra Ellen Gracie, **1679**, relator Ministro Gilmar Mendes, e **4261**, da relatoria do Ministro Carlos Ayres Britto, razão pela qual deve ser conhecida a ação.

II. Do dispositivo impugnado

Inicialmente cabe expor a sucessão de normas que especifica as atribuições do cargo de Técnico Superior nos quadros da Faculdade de Música do Espírito Santo – FAMES/ES.

É que o art. 1º da Lei Complementar 739/2013 que aqui se impugna alterou o Anexo III da Lei Complementar 714/2013.

A LC 714/2013, originalmente, dispunha sobre o plano de cargos e *Carreiras e Vencimentos para os Servidores da Faculdade de Musica do Espírito Santo - FAMES-ES.* O artigo 5º desta lei criou os cargos de carreira de Técnico Superior, com as atribuições definidas no Anexo III da citada Lei Complementar. Para o cargo de Técnico Superior exigiu formação em ensino superior em diversas áreas, conforme anexo V, da correspondente lei.

> **"Art. 5º Ficam criadas no Quadro de Pessoal Permanente da FAMES-ES as carreiras de Professor Titular, professor**

Adjunto professor Assistente, Professor Auxiliar de Ensino, Técnico de Nível Superior e Assistente Administrativo, compostas por cargos de provimento efetivo, cujas atribuições, número de vagas e requisitos para provimento estão definidos nos Anexos I e III desta Lei Complementar.

ANEXO III
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS CARGOS
PARTE PERMANENTE DO QUADRO DE PESSOAL

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR
REQUISITO DE INGRESSO:
Bacharelado em Administração; Administração Pública/Gestão Pública; Arquivologia; Biblioteconomia; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Ciência da Computação; Comunicação Social; Direito; Pedagogia; Psicologia; Sistemas de Informação e Serviço Social. Registro no órgão de classe com habilitação legal para o exercício da profissão, quando esta for regulamentada, na forma da legislação em vigor.
ATRIBUIÇÃO:
Acompanhar, controlar e executar as atividades administrativas e técnicas, em relação às áreas de planejamento, recursos humanos, finanças, orçamento, patrimônio, informática e de métodos e processos de trabalho, respeitados os regulamentos próprios; Acompanhar e avaliar esforços, pessoas e recursos para o desenvolvimento e execução de planos, ações e projetos, buscando garantir o atendimento das prioridades, prazos, padrões de qualidade e eficácia das políticas implementadas; Prestar atendimento ao público, de acordo com as especificidades de sua área de atuação; Elaborar documentos diversos, captando, analisando, consolidando dados e informações para revisão

dos planos de trabalho; Formular, planejar, analisar e executar projetos estratégicos relacionados diretamente com sua área de formação/conhecimento específico; Identificar e propor melhorias nos projetos/processos existentes; Levantar e mapear requisitos necessários para a formulação de novas ações institucionais; Executar outras atividades correlatas.
VAGAS:
06

O Anexo III da LC 714 foi alterado pelo art. 1º da LC 739, da seguinte forma:

> **"Art. 1º** O Anexo III da Lei Complementar n.º 714, de 15.10.2013, passa a vigorar com alteração constante do Anexo Único desta lei Complementar.

ANEXO ÚNICO, a que se refere o artigo 1º desta Lei Complementar.

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO CARGO DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR

PARTE PERMANENTE DO QUADRO DE PESSOAL

Cargo: Técnico de Nível Superior

Requisito de Ingresso:

Bacharelado em Administração; Administração Pública/Gestão Pública; Arquivologia; Biblioteconomia; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Ciência da Computação; Comunicação Social; **Direito**; Pedagogia; Psicologia; Sistemas de Informação e Serviço Social.

Registro no órgão de classe com habilitação legal para o exercício da profissão, quando esta for regulamentada, na forma da legislação em vigor.

Atribuição:

Acompanhar, controlar e executar as atividades administrativas e técnicas, em relação às áreas de planejamento, recursos humanos, finanças, orçamento, patrimônio, informática e de métodos e processos de trabalho, respeitados os regulamentos próprios; acompanhar e avaliar esforços, pessoas e recursos para o desenvolvimento e execução de planos, ações e projetos, buscando garantir o atendimento das prioridades, prazos, padrões de qualidade e eficácia das políticas implementadas; prestar atendimento ao público, de acordo com as especificidades de sua área de atuação; elaborar documentos diversos, captando, analisando, consolidando dados e informações para revisão dos planos de trabalho; formular, planejar, analisar e executar projetos estratégicos relacionados diretamente com sua área de formação/conhecimento específico; identificar e propor melhorias nos projetos/processos existentes; levantar e mapear requisitos necessários para a formulação de novas ações institucionais; executar outras atividades correlatas.

ATRIBUIÇÕES COMPLEMENTARES E ESPECÍFICAS – FORMAÇÃO DIREITO: Interagir com as demais unidades administrativas da autarquia na elaboração de normas, instruções, resoluções e demais atos a serem expedidos; interpretar textos e instrumentos legais; elaborar estudos de pareceres sobre questões jurídicas que envolvam as atividades da FAMES; elaborar editais, contratos, convênios, acordos e ajustes celebrados pela Autarquia, com a emissão de parecer; representar a Autarquia judicial ou extrajudicialmente nas ações de seu interesse; acompanhar o andamento dos processos; apresentar recursos em qualquer instância; promover medidas administrativas e judiciais para proteção dos bens e patrimônio da FAMES; desempenhar outras atribuições de natureza jurídica, conforme determinação superior e de acordo com o interesse público.

Pré-requisito Básico:

Inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.

Conforme se observa, o art. 1º e Anexo Único da Lei Complementar nº 739/2013 atribui aos Técnicos Superiores da FAMES formados em Direito e inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil a função de representar, judicial e extrajudicialmente, a autarquia nas ações em que haja interesse desta, prevendo, dentre outras atribuições, a de interpor recursos, comparecer a audiências e praticar todos os atos de natureza judicial ou contenciosa que se revelem necessários. Os dispositivos também outorgam aos ocupantes desse cargo a atribuição de consultoria e assessoramento jurídicos da autarquia, cabendo-lhe, dentro outras atividades, elaborar contratos, convênios, acordos, emitir pareceres, etc.

Neste panorama, pode-se dizer que há dentro da estrutura da FAMES cargo de Técnico Superior que usurpa atribuições de Procurador de Estado.

III. Da violação ao art. 132 da Constituição

Extrai-se dos termos da Lei Complementar nº. 739/2013 que esta se destina a especificar as atribuições do cargo de Técnico Superior, com formação em Direito e registro nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, no âmbito da Faculdade de Música do Espírito Santo, contudo em frontal violação ao que dispõe a *Carta*.

É que ao prever para os Técnicos Superiores com formação em Direito a função de representar a FAMES em juízo ou fora dele, nas ações em que haja interesse da autarquia e conferir-lhes atribuições de consultoria e assessoramento jurídico, a norma invade a competência atribuída constitucionalmente aos Procuradores do Estado do Espírito Santo, violando de maneira direta o art. 132, da Constituição Federal, que é categórico ao dispor o seguinte:

> Art.132. Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas.

O sistema unitário de Advocacia Pública para os Estados da federação e o Distrito Federal adotado pelo mandamento constitucional vigente

desde 1988 operou e consolidou modelo em que toda a defesa judicial e o consultivo jurídico de cada unidade federada estão a cargo das Procuradorias Gerais. Por esta razão, as Procuradorias Gerais dos Estados e do Distrito Federal sempre atuaram como instituições voltadas para a viabilização das políticas públicas, na forma determinada pela Constituição e pelas leis.

Desse modo, a Lei Complementar nº. 739/2013, além de contrariar o artigo 132, da Constituição Federal, pode gerar profunda perturbação em estruturas já consolidadas, além de violar o princípio da unidade e exclusividade indispensável à eficiência dos serviços jurídicos. Nesse contexto, portanto, a Lei Complementar nº. 739/2013 representa enorme retrocesso institucional no longo caminho percorrido pelo Estado do Espírito Santo para a estruturação de seus serviços jurídicos, causando insegurança nos meios político e administrativo.

Isso porque a **unidade** e **exclusividade** dos serviços jurídicos aos Procuradores de Estado e do Distrito Federal, de acordo com o que já dispõe o art. 132, CF, também estão consagradas originariamente no art. 69, dos Atos e Disposições Constitucionais Transitórios, *in verbis*:

> **Art. 69. Será permitido aos Estados manter consultorias jurídicas separadas de suas Procuradorias-Gerais ou Advocacias-Gerais, desde que, na data da promulgação da Constituição, tenham órgãos distintos para as respectivas funções.** (Grifo nosso)

Este dispositivo constituiu excepcional exceção ao princípio da unidade orgânica da representação judicial e da consultoria jurídica dos Estados-Membros e do Distrito Federal e, por isso, autorizou a manutenção, nestas

unidades federadas, **apenas das consultorias existentes anteriormente à promulgação da Constituição de 1988**.

Entretanto, na hipótese vertente dos autos a Lei Complementar nº. 739/2013 do Espírito Santo estabelece as atribuições do cargo de Técnico Superior da FAMES mais de 20 (vinte) anos após a promulgação da Constituição Federal.

Assim, por interpretação contrária ao art. 69, do ADCT, conclui-se que caso tenham sido institucionalizadas ou positivadas depois da promulgação da Constituição da República, a exemplo da hipótese vertente, os órgãos jurídicos descentralizados padecem de vício de inconstitucionalidade original.

Nesse sentido decidiu o STF no julgamento da ADI 484, ao aplicar interpretação conforme em relação a leis do Estado do Paraná que criavam a carreira de advogado estadual com atribuições de representação judicial e extrajudicial na administração direta e na autárquica. Ficou decidido que a existência de carreira de advocacia pública em paralelo à de Procurador do Estado ofende o art. 132 da CF, admitida apenas em relação ao contemplados pelo art. 69 do ADCT. Proibiu-se, expressamente, a criação de carreira permanente de advogados públicos em duplicidade com a de Procuradores do Estado, vedando a realização de novos concursos públicos para preencher as vagas criadas pela lei destinadas exclusivamente aqueles servidores agraciados pelo art. 69 do ADCT. Segue a ementa do julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS ESTADUAIS 9.422, DE 5/11/1990, E 9.525, DE 8/1/1991. CRIAÇÃO DA CARREIRA ESPECIAL DE ADVOGADO DO ESTADO DO PARANÁ, INTEGRADA PELOS OCUPANTES DE EMPREGOS E CARGOS PÚBLICOS DE ADVOGADOS E ASSISTENTES JURÍDICOS ESTÁVEIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA DAQUELA UNIDADE FEDERADA. ATRIBUIÇÕES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO PODER EXECUTIVO E DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DAS AUTARQUIAS, COORDENADAS PELO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO. ARTS. 5º, I, 37, II E XIII, 132 E 169, DA CF, E ART. 19, § 1º, DO ADCT. ALEGAÇÕES DE OFENSA REJEITADAS. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO FEDERAL CONFERIDA AO ART. 5º DA LEI 9.422/1990. I – O Plenário desta Corte, no julgamento definitivo da ADI 175/PR, Rel. Min. Octavio Gallotti, declarou a constitucionalidade do art. 56 e parágrafos do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado do Paraná, de 5/10/1989, que autorizou a permanência, em carreiras especiais criadas por lei, dos que já ocupavam com estabilidade, naquele momento, cargos e empregos públicos de advogados, assessores e assistentes jurídicos, para o exercício do assessoramento jurídico nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e da representação judicial das autarquias e fundações públicas. II – Os diplomas legais ora impugnados, ao reunirem numa única carreira os então ocupantes de empregos e cargos públicos preexistentes que já exerciam as mesmas funções de assessoramento jurídico ao Poder Executivo e de representação judicial das autarquias, nada mais fizeram do que atender ao comando expresso no mencionado art. 56 do ADCT paranaense, tratando-se, por certo, de hipótese de subsistência excepcional e transitória autorizada pelo art. 69 do ADCT da Constituição Federal. III – A previsão de concurso público de provas e títulos para ingresso na nova carreira, contida no art. 5º da Lei Estadual 9.422/1990, destinou-se, exclusivamente, àqueles que já eram, no momento de edição da norma constitucional transitória, ocupantes estáveis de cargos e empregos públicos de advogados, assessores e assistentes jurídicos e que viriam a

> preencher, mediante aproveitamento, os 295 cargos criados pelo art. 2º do mesmo diploma. IV – Impossibilidade, na vacância, de provimento dos cargos da Carreira Especial de Advogado do Estado do Paraná por outros servidores e, por conseguinte, de realização de novos concursos públicos para esse fim. Necessidade de obediência ao art. 132 da Constituição Federal. V – Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente, com interpretação conforme, nos termos supra.
> (ADI 484, Relator(a): Min. EROS GRAU, Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2011, DJe-022 DIVULG 31-01-2012 PUBLIC 01-02-2012 EMENT VOL-02642-01 PP-00001)

Faz-se oportuno destacar o entendimento manifestado pela ilustre Ministra Carmen Lúcia no julgamento da ADI nº. 484/PR, em que afirma existir apenas um órgão de serviços jurídicos nos Estados e no Distrito Federal, diferentemente do que ocorre com as autarquias e fundações, que por lei são criadas ou autorizadas e por lei são extintas ou postas em liquidação, de modo que somente os profissionais investidos anteriormente à promulgação da Constituição de 1988 poderiam ser mantidos nos quadros dos órgãos especiais de que trata esse artigo 69, do ADCT:

> Nesses termos, realço o que já assentado por este Supremo Tribunal, no sentido de que "*o art. 132 da Constituição veicula norma de organização administrativa.*", não sendo vedado, portanto, em situações específicas e a critério das entidades federadas, o exercício, por outros advogados, sempre em caráter excepcional, das atribuições constitucionalmente atribuídas aos Procuradores de Estado (PET n. 408-AgR, Redator para o acórdão Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 26.6.1990).
> A *contrario sensu*, **o exercício regular das atribuições constitucionalmente definidas no art. 132 deverá ser desempenhado por quem aquela norma afirmou: os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, ingressos na**

carreira por meio de concurso público de provas e títulos, no qual se assegure a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases.

Não vislumbro, com as devidas vênias, a possibilidade de se extrair do art. 132 autorização constitucional para a coexistência, nas unidades federadas, de Procuradorias paralelas, ainda que com nomes diversos, nem há outros legitimados para o exercício regular e ordinário da representação judicial e da consultoria jurídica, menos ainda no âmbito do Poder Executivo.

A propósito, **relembro o voto do eminente Ministro Celso de Mello no julgamento de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face de lei complementar do Estado do Espírito Santo**, que qualificou os cargos de Assessor Jurídico do Poder Executivo local, para o desempenho de funções de assessoramento, assistência e consultoria jurídica, como sendo de livre nomeação e exoneração (ADIn n. 881, Plenário, DJ 25.4.1997):

> "os Procuradores do Estado são, na realidade, os Advogados do Estado. Essa expressiva condição funcional decorre de um título jurídico fundado na própria Constituição Federal: o ato de sua investidura, mediante prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, no relevantíssimo cargo de membro integrante da Advocacia do Estado, órgão ao qual incumbe, dentre outras atribuições, a consultoria jurídica do Poder Executivo.
>
> **O desempenho das atividades de assessoramento jurídico no âmbito do Poder Executivo estadual traduz prerrogativa de índole constitucional outorgada pela Carta Federal aos Procuradores do Estado (art. 132). Operou-se, nesse referido preceito da Constituição, uma inderrogável imputação de específica atividade funcional cujos destinatários são, exclusivamente, os Procuradores do Estado, agentes públicos cujo processo de investidura originária no cargo que exercem depende, sempre, de aprovação em concurso público.**
>
> ...

> A exclusividade dessa função de consultoria remanesce, agora, na esfera institucional da Advocacia Pública, exercida, no pleno dos Estados-membros, por suas respectivas Procuradorias Gerais e pelos membros que as compõem.
> Essa prerrogativa institucional, que é de ordem pública, encontra assento na própria Constituição Federal. Não pode, por isso mesmo, comportar exceções e nem sofrer derrogações que o texto constitucional sequer autorizou ou previu."

E o disposto no art. 69 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias antes comprova esse entendimento do que o infirma, uma vez que, assim como o art. 132 do corpo normativo permanente da Constituição da República, também veicula norma eminentemente de organização administrativa.
Nessa linha, o art. 69 do ADCT apenas admite a manutenção de "*consultorias jurídicas separadas de suas Procuradorias-Gerais ou Advocacias-Gerais, desde que, na data da promulgação da Constituição, tenham órgãos distintos para as respectivas funções*".
[...]
A representação judicial, aliás, é ínsita ao exercício da advocacia, pelo que também afastado o dispositivo transitório mencionado em relação ao cargo de Advogado Público.
Por esse motivo, ao destinar essa função de representação judicial somente aos Advogados das Fundações Públicas (art. 15, § 1º), a Lei n. 9.422/90 também modificou as atribuições originárias dos cargos por ela abarcados, realizando, assim, verdadeira criação de nova carreira, [...].
Poder-se-ia mesmo invocar, aqui, a Súmula n. 685, deste Supremo Tribunal, segundo a qual é "*inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido*". (Grifo nosso)

Extrai-se, portanto, que a Lei Complementar nº. 739/2013, do Estado do Espírito Santo, ao promover a criação de carreira paralela à de

Procurador do Estado não pode se adequar ao ordenamento jurídico pátrio por se tratar de lei manifestamente inconstitucional. O entendimento foi reproduzido também no julgamento da ADI 881:

> AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI COMPLEMENTAR 11/91, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ART. 12, CAPUT, E §§ 1º E 2º; ART. 13 E INCISOS I A V) - ASSESSOR JURÍDICO - CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - FUNÇÕES INERENTES AO CARGO DE PROCURADOR DO ESTADO - USURPAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES PRIVATIVAS - PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. - O desempenho das atividades de assessoramento jurídico no âmbito do Poder Executivo estadual traduz prerrogativa de índole constitucional outorgada aos Procuradores do Estado pela Carta Federal. A Constituição da República, em seu art. 132, operou uma inderrogável imputação de específica e exclusiva atividade funcional aos membros integrantes da Advocacia Pública do Estado, cujo processo de investidura no cargo que exercem depende, sempre, de prévia aprovação em concurso público de provas e títulos.
>
> (ADI 881 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 02/08/1993, DJ 25-04-1997 PP-15197 EMENT VOL-01866-02 PP-00238)

Esta conclusão se obtém da interpretação do art. 132, CF c/c art. 69, do ADCT, bem como da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que vedam a instituição de serviços jurídicos autônomos para a defesa de interesses de autarquias e fundações públicas estaduais, paralelo às Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal.

Nesse sentido, aliás, foi o entendimento deste Colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 1679/GO, em que restou assentado que a descentralização funcional das Procuradorias-Gerais dos Estados é inconstitucional.

> Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Emenda Constitucional no 17, de 30 de junho de 1997, promulgada pela Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, que acrescentou os §§ 2o e 3o e incisos, ao artigo 118 da Constituição estadual. 3. Criação de Procuradoria da Fazenda Estadual, subordinada à Secretaria da Fazenda do Estado e desvinculada à Procuradoria-Geral. 4. Alegação de ofensa aos artigos 132 da Constituição e 32, do ADCT. 5. Descentralização. Usurpação da competência funcional exclusiva da Procuradoria-Geral do Estado. 6. Ausência de previsão constitucional expressa para a descentralização funcional da Procuradoria-Geral do Estado. 7. Inaplicabilidade da hipótese prevista no artigo 69 do ADCT. Inexistência de órgãos distintos da Procuradoria estadual à data da promulgação da Constituição. 8. Ação julgada procedente
>
> (ADI 1679, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 08/10/2003, DJ 21-11-2003 PP-00007 EMENT VOL-02133-02 PP-00209)

No voto condutor da ADI 1679, o Ministro Gilmar Mendes destaca que

> (...) *a leitura conjunta dos artigos 132 da Constituição e 69 do ADCT não permite que se conceba uma estrutura plural para a advocacia pública dos Estados-membros. A exceção prevista no art. 69 do ADCT indica cabalmente que a tolerância do sistema constitucional para com um modelo descentralizado há de ficar limitada às Consultorias Jurídicas separadas da*

> *Procuradoria-Geral existentes na data da promulgação da Constituição.*

Com efeito, diante da ausência de permissão expressa de descentralização, não é possível, por óbvio, conferir ao artigo 132, da Constituição Federal, interpretação analógica ou extensiva, sob pena de se romper o princípio da unidade e exclusividade consagrado originariamente na Constituição Federal.

Isso porque a instituição de serviço jurídico autônomo consubstancia patente usurpação da competência funcional exclusiva atribuída aos Procuradores do Estado, encontrando óbice, por conseguinte, tanto no art. 132, CF, quanto no art. 69, do ADCT.

Conforme voto proferido pelo Ministro Ayres Brito na ADI 4261

> *no âmbito do Poder Executivo, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico são exclusivamente confiadas pela Constituição Federal aos procuradores de Estado, com organização em carreira e ingresso por concurso público de provas e títulos, exigida ainda a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases. Isso como condição de qualificação técnica e independência funcional. Independência e qualificação que hão de presidir a atuação de quem desenvolve as atividades de orientação e representação jurídica, tão necessárias ao regular funcionamento do Poder Executivo.*

Acrescente-se, ainda, por oportuno, que a Lei Complementar nº. 88/1996, do Estado do Espírito Santo, que regula a Procuradoria Geral do

Estado, é categórica ao prever as atribuições dos Procuradores do Estado, dentre as quais se inclui, no art. 3º, I, "*representar judicial e extrajudicialmente o Estado, suas autarquias e fundações públicas, exercendo privativamente a sua consultoria e assessoramento jurídico.*"

Assim não há dúvida que a Lei Complementar nº. 739/2013 do Estado do Espírito Santo, objeto da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, representa evidente prejuízo ao princípio administrativo da eficiência. A inclusão dos "*técnicos-procuradores*" entre os advogados públicos conduz, naturalmente, à descentralização da Advocacia Pública Estadual, e a adoção dessa opção político-normativa afeta a racionalidade e eficiência da atividade desenvolvida pelos Procuradores do Estado do Espírito Santo, em especial no que se refere à uniformização dos seus pronunciamentos, com reflexos sobre o princípio administrativo da eficiência.

Por estas razões, não é possível, como pretende a Lei Complementar nº. 739/2013, qualquer reforma que permita, no âmbito do Estado do Espírito Santo ou em quaisquer dos Estados-membros e do Distrito Federal, a convivência da respectiva Procuradoria-Geral com denominadas "***procuradorias autárquicas e fundacionais***", sob pena de violação ao comando expresso da Constituição Federal de 1988 e aos princípios da unicidade, exclusividade, eficiência, eficácia e racionalidade administrativas.

A intenção da *Carta Magna* é assegurar que os entes federados, e seus órgãos da administração direta e indireta, sejam atendidos por profissionais que integram a chamada Advocacia Pública Estadual, ou seja, por

advogados aprovados em "*concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases*".

Tanto é assim que a Constituição Federal conferiu meios e atribuições às Procuradorias Gerais dos Estados e do Distrito Federal a fim de que estas pudessem atender, em caráter de exclusividade, as entidades fundacionais e autárquicas, como a FAMES.

Estabelecidas tais premissas, conclui-se então que caso não seja declarada a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº. 739/2013 do Estado do Espírito Santo, o que apenas para fins de argumentação se permite aduzir, a sua permanência no ordenamento jurídico representará afronta direta à Constituição Federal na medida em que permite a coexistência, no Estado do Espírito Santo, de Procuradorias paralelas, ainda que com nomes diversos, quando, na realidade, a Constituição assegura e determina que a representação judicial e assessoria jurídica dos entes devem ser exercidas pela Procuradoria Geral do Estado com exclusividade e unicidade.

Evidente, portanto, que o exercício regular das atribuições constitucionalmente definidas no art. 132 deverá ser desempenhado pelos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, ingressos na carreira por meio de concurso público de provas e títulos e, que, por conseguinte, as funções atribuídas pela Lei Complementar nº. 739 aos Técnicos Superiores da FAMES com formação em Direito e inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil devem ser exercidas com exclusividade pelos Procuradores do Estado do Espírito Santo, com base no texto constitucional e na Lei Complementar nº.

88/1996, imperiosa se revela a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº. 739 do Estado do Espírito Santo por esta Colenda Corte.

IV. Da ofensa ao art. 32, II, da CF

O artigo 1º da LC 739 acarreta inconstitucional transformação do cargo de Técnico de Nível Superior da FAMES-ES, o que configura ofensa ao disposto no art. 32, II da CF. Este dispositivo legal confere aos ocupantes do cargo de Técnico de Nível Superior com formação em Direito, com funções outrora exclusivamente administrativas, atribuições típicas de "advogados públicos".

Na sua feição original o cargo de Técnico de Nível Superior exigia apenas formação em nível superior (art. 5º, º da LC 714), que detinha atribuições destinadas apenas *"[...] a desenvolver ações voltadas para regulação, controle, auditoria e fiscalização das atividades relacionadas ao trânsito, cujas atribuições requeiram, do ocupante, formação de nível superior"*. O cargo sequer era exclusivo de graduados em direito, admitindo-se que o servidor tivesse formação em Administração; Administração Pública/Gestão Pública; Arquivologia; Biblioteconomia; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Ciência da Computação; Comunicação Social; Direito; Pedagogia; Psicologia; Sistemas de Informação e Serviço Social.

O artigo 1º da LC 739, por sua vez, teve como efeito conferir ao cargo de Técnico de Nível Superior com formação em direito, nomeados no

cargo antes da entrada em vigor da lei em referência, a função de representação judicial e extrajudicial da autarquia, função esta considerada típica e exclusiva de advogado público.

De se ver, os servidores nomeados antes da LC 739 haviam prestado concurso público para o cargo de Técnico Superior, cujas atribuições eram exclusivamente de apoio administrativo. Com o advento da LC 739, estes mesmo servidores com formação em Direito, foram, inconstitucionalmente, alçados a um novo patamar, com atribuições exclusivas de advogado público. A transformação do cargo de Técnico de Nivel Superior para Técnico de Nível Superior com formação jurídica desrespeita a regra do concurso público, pois, em última análise, os servidores outrora nomeados não foram submetidos a concurso público para cargo com funções de representação judicial e extrajudicial.

É clara a inconstitucionalidade do dispositivo em voga, ao conferir uma modalidade de provimento derivado aos servidores nomeados anteriormente à LC 739, via transformação do cargo, desrespeitando a exigência de prévia aprovação em concurso público específico, violando o disposto no art. 37, II, da CF. Neste sentido, precedentes do STF:

> EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DA RESOLUÇÃO N. 825/2002, DA ASSEMBLEIA DO ESTADO DE SÃO PAULO: AFRONTA AO ART. 37, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Preliminar de falta de

interesse de agir por ausência de impugnação das Leis Complementares paulistas ns. 865 e 881/2000: objeto diverso daquele contida na Resolução. Preliminar afastada. 2. Possibilidade de impugnação de Resolução por meio de ação direta de inconstitucionalidade, nos casos em que por meio dela se formalize ato normativo e autônomo. 3. Inconstitucionalidade formal não configurada. Arts. 51, inc. IV, e 52, inc. XIII, da Constituição da República: competência das Casas Legislativas para dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços. 4. Inconstitucionalidade material configurada: art. 37, inc. II, da Constituição brasileira; afronta à regra constitucional da prévia aprovação em concurso público. Forma de provimento derivado de cargo público abolida e vedada pela Constituição da República. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 3342, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 04/03/2009, DJe-099 DIVULG 28-05-2009 PUBLIC 29-05-2009 EMENT VOL-02362-05 PP-00840 LEXSTF v. 31, n. 365, 2009, p. 62-74)

EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 1.626, de 11 de setembro de 1997, do Distrito Federal. - Já se firmou o entendimento desta Corte no sentido de que, também em face da atual Constituição, as normas básicas da Carta Magna Federal sobre o processo legislativo, como as referentes às hipóteses de iniciativa reservada, devem ser observadas pelos Estados-membros e pelo Distrito Federal. - No caso, a lei distrital em causa não só cria, por transformação, cargos, mas também trata de seu provimento, sem que sua iniciativa tivesse partido do Governador do Distrito Federal, o que ofende o disposto nas letras "a" e "c" do inciso II do § 1º do artigo 61 da Carta Magna Federal. - Por outro lado, procede, também, a argüição de

inconstitucionalidade material do artigo 3º da mesma Lei distrital, porquanto ele determina que, nos novos cargos de fiscal tributário, haja o aproveitamento dos servidores dos cargos extintos de técnico tributário, sem, portanto, a prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos como exige, para a investidura, que não mais se limita à primeira, de cargo ou emprego público, o disposto no inciso II do artigo 37 da Constituição, que, nesse ponto, a Emenda Constitucional nº 19/98 o manteve como redigido originariamente, razão por que pode servir de parâmetro para a aferição da inconstitucionalidade em causa. Ação direta de inconstitucionalidade que se julga procedente, para se declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 1.626, de 11 de setembro de 1997, do Distrito Federal. (ADI 1677, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 03/02/2003, DJ 28-03-2003 PP-00061 EMENT VOL-02104-01 PP-00124)

_____

EMENTA: CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL QUE CRIA GRUPO ESPECIAL DE ADVOGADOS COMPOSTO POR OCUPANTES DE CARGO PÚBLICO DE ADVOGADO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL. CARACTERIZADO O ENQUADRADAMENTO AUTOMÁTICO, SEM CONCURSO PÚBLICO. OFENSA AO ART. 37, II, DA CF. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. (ADI 824, Relator(a): Min. NELSON JOBIM, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2001, DJ 10-08-2001 PP-00002 EMENT VOL-02038-01 PP-00069)

_____

TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS DE ASSISTENTE JURÍDICO (E ASSEMELHADOS) EM OUTROS DE CONSULTOR JURÍDICO, COM OS MESMOS DIREITOS E

> DEVERES DOS PROCURADORES DO ESTADO. NORMAS DA CONSTITUIÇÃO DO PARA (PARAGRAFOS 2. E 4. DO ART. 310); IMPUGNADAS PERANTE OS ARTIGOS 37, II E XIII DA CARTA FEDERAL E ART.19, PAR. 1. DO ADCT DE 1988. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. (ADI 159 MC, Relator(a): Min. OCTAVIO GALLOTTI, Tribunal Pleno, julgado em 18/04/1990, DJ 25-05-1990 PP-04603 EMENT VOL-01582-01 PP-00047)

Portanto, também pela violação ao princípio constitucional do concurso público, inconstitucional a norma.

V. Da necessidade de concessão de medida cautelar

Os arts. 10 e seguintes da Lei Federal n° 9.868/99 estabelecem a possibilidade de concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade demonstrada a presença do *fumus boni juris* e do *periculum in mora*.

Inegáveis se demonstram a relevância e a pertinência jurídica dos fundamentos destacados na presente exordial, os quais por si só justificam a necessidade de suspensão dos efeitos jurídicos da Lei Complementar nº. 739/2013 do Estado do Espírito Santo até o julgamento final desta Ação Direta de Inconstitucionalidade, sobretudo para que se assegure a preservação da garantia constitucional indicada e violada, qual seja, a competência exclusiva dos Procuradores do Estado do Espírito Santo para representar judicial e extrajudicialmente o Estado, suas autarquias e fundações, revelando-se inadmissível que a representação judicial da FAMES seja exercida por Técnicos

Superiores formados em Direito e inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil.

Assim, o *fumus boni juris*, neste caso, está plenamente demonstrado pelas razões de direitos acima exposta.

Por outro lado, tem-se a presença do *periculum in mora* consubstanciada inicialmente na prática de **atos nulos**, como a confecção de peças jurídicas no assessoramento, consultoria e representação judicial da Faculdade de Música do Espírito Santo através de servidores que usurpam atribuições constitucionais dos Procuradores de Estado. A insegurança jurídica somente tende a aumentar, com o grave risco de dilapidação do erário, o que revela o grande interesse público envolvido.

Além disso, a jurisprudência desta Excelsa Corte entende, de forma pacífica, que em sede de controle abstrato o requisito do perigo da demora pode se fazer presente sem prejuízo ao devido processo legal diante da conveniência da medida cautelar do ponto de vista dos efeitos que ela visa produzir.

Some-se a isso a **cotidiana preterição dos Procuradores do Estado na atividade de consultoria jurídica, em perene e constante afronta ao preceptivo constitucional** cuja violação sustenta o presente pleito.

Caso a Corte não aceite o argumento antes deduzido, requer seja concedida a medida cautelar em razão da conveniência já exposta de se delimitar juridicamente as atribuições da carreira de Procurador do Estado para evitar o quadro de incertezas decorrentes da discussão da presente ADI

(imagine-se, por exemplo, a possibilidade de anulação de processos administrativos instruídos com pareceres emitidos por **Técnicos Superiores**).

A medida cautelar teria o condão, portanto, de tornar seguros os campos de competências dos Procuradores do Estado e demonstrar a impossibilidade da existência de cargos de Técnicos Superiores com as mesmas atribuições, afastando quaisquer questionamentos e garantindo o regular funcionamento da Administração Pública e a atuação dos titulares.

Ademais, veja-se que, na prática, a simples submissão ao **rito do art. 12 da Lei n°9.868/1999** pode muitas vezes **não ser suficiente**. Aliás, cumpre mencionar aqui a medida cautelar deferida nos autos da ADI 4.843/PB não obstante seu processamento pelo rito abreviado, o que reforça a possibilidade e necessidade de provimento da cautela.

VI. Dos Pedidos

Diante do exposto, requer:

a) A concessão da medida cautelar postulada para que sejam suspendidos, liminarmente, até o julgamento final desta Ação Direta de Inconstitucionalidade, todos os efeitos da Lei Complementar nº. 739/2013 do Estado do Espírito Santo;

b) A notificação do Exmo. Sr. Governador do Estado do Espírito Santo e da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo para apresentarem informações;

c) A notificação do Exmo. Sr. Advogado-Geral da União e do Exmo. Sr. Procurador Geral da República para que opinem;

d) O julgamento de procedência da presente ação para que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº. 739/2013 do Estado do Espírito Santo, pelos argumentos fáticos e jurídicos delineados acima.

Requer que as **publicações** sejam realizadas no nome do advogado **CEZAR BRITTO**, OAB/DF 32.147.

Espera deferimento.

Brasília/DF, 17 de setembro de 2014.

CEZAR BRITTO
OAB/DF 32.147

RODRIGO MESQUITA
OAB/DF 41.509

DANILO PRUDENTE LIMA
OAB/DF 42.790